

被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離に関する次のアからエまでの各記述のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 弁論併合前に、甲に対する関係で取調べ済みの証拠は、弁論併合により、その効果として、乙に対する関係でも証拠となる。
- イ. 弁論併合後に、検察官が証拠調べ請求し、裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても、甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
- ウ. 弁論併合後に、検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し、甲の弁護人が同意、乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は、弁論を分離しない限り、裁判所は、甲に対する関係でも、この検察官面前調書を証拠として採用し、取調べをすることはできない。
- エ. 弁論併合後に、弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは、証人となった甲に黙秘権が認められないにもかかわらず、尋問の結果作成された甲の証人尋問調書は刑事訴訟法第322条の要件を満たす限り、甲の被告事件においても証拠能力を取得することとなり、結局甲の黙秘権保障に反する結果となるから、許されない。

ア 誤っている

弁論の併合とは、数個の事件の弁論を同時に併行して行うことをいう。弁論の併合は手続を1個で済ますことにその目的があるから、その手続内で行われた1個の訴訟行為は、法律上又は事実上事件ごとに効果が生じるべきものを除き、併合された事件全部にその効果が生じる。ただし併合前の手続は互いに別個独立の審理手続であったものであるから、相互に影響し合うことはない。すなわち、併合前に被告人のために取り調べた証拠が、併合することによって、当然に他の共同被告人の関係でも証拠になるというわけではない(最判昭45.11.5)。よって、弁論併合前に、甲に対する関係で取調べ済みの証拠が、弁論併合により、その効果として、乙に対する関係でも証拠となるわけではない。

イ 正しい

刑事裁判においては、被告人に反対尋問権があり(憲法37条2項、刑訴法304条)、また、いわゆる伝聞法則があるので、自らが反論を加えられない証拠を有罪認定に用いるのは、合理的な例外がない限り原則として許されず、いわゆる証拠共通の原則は認められない。それゆえ、弁論併合後でも、特定の被告人との関係においてのみ調べられたものは、その被告人のみの証拠とされる。よって、弁論併合後に、検察官が証拠調べ請求し、裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても、甲または乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。

ウ 誤っている

共同被告人といっても、訴訟法律関係はもともと別個であるから、一部の被告人についてのみ限定して、訴訟行為が行われることも可能である(法律関係の個別性)。被告人間で書証の同意、不同意が分かれた場合、同意した証拠は、同意した被告人との関係のみで証拠能力を有する。不同意とした共同被告人との関係では、これに代わる証人尋問が必要となってくる。よって、弁論併合後に、検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し、甲の弁護人が同意、乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合、弁論を分離しなくとも、裁判所は、甲に対する関係で、この検察官面前調書を証拠として採用し、証拠調べをすることができる。

エ 誤っている

共同被告人であっても、弁論を分離すれば共同被告人でなくなるから、分離前の相被告人の事件につき証人として尋問することは可能になる。しかし、その場合にも常に無条件で証人として尋問することを許されるかどうかは議論がある。消極説は、被告人は、自分の事件の関係では、終始沈黙したり供述を拒否できるのに対し、証人として尋問される事件の関係では、証言拒否によってその事実について自分が有罪であることを暗示するか、さもなくば偽証の制裁の威嚇の下に供述を余儀なくされるかのどちらかであって、いずれにしても憲法38条1項の精神からすると、甚だ問題があるため、その被告人の意思に反して証人に喚問することはできないものと解するか、少なくとも、その証言を供述者自身の犯罪事実に対する関係では、証拠に採れないものと解すべきとする。しかし、最判昭35.9.9は、併合審理の途中で1人の被告人の事件を分離すれば、その者は共同被告人ではなくなるから証人として尋問することが可能となるし、さらに後にその者を再度併合した場合にはその証人尋問調書を同人に対する関係で322条の証拠として用いることも支障ないとしている。よって、弁論併合後に、弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは許される。